

1500607-08.2022.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... que já teve condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecentes. Afirmou que não contou das ameaças para os agentes penitenciários que se encontravam no "scanner", pois a mulher que lhe prometeu mal injusto e grave estava logo atrás na fila. Disse que seu marido está preso por tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500607-08.2022.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 15 de agosto de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500607-08.2022.8.26.0344 - Controle 2022/000351

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALQUIRIA DA SILVA GILARDI

Vistos.

VALQUIRIA DA SILVA GILARDI, (RG: 40.318.004, filha de Wagner Gilardi e Lucinete Pedro da Silva), foi denunciada como incurso no artigo 33 c.c. o artigo, 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 14h17min, na Penitenciária de Marília, situada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 465, nesta cidade e comarca de Marília/SP, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 74,96g (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahydrocannabinol, substância entorpecente que determina dependência psíquica. Recebida a denúncia (fls. 148/150), a ré foi citada (fls. 161) e apresentou resposta à acusação (fls. 169/178).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, sendo, a acusada, interrogada ao final.

Alegações finais da acusação e da defesa no termo de audiência de fls. 222/230.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitativa se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em

flagrante (fls. 3/9), boletim de ocorrência (fls. 10/11), comunicação de evento da penitenciária (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15), fotografia (fls. 16), laudo de constatação (fls. 18/20), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 127/130), e pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

Na fase inquisitiva (fls. 4), a testemunha Ana Paula Almeida de Miranda, agente penitenciária, declarou que, na data dos fatos, durante a visita dos presos, verificaram pelo "scanner corporal" que a acusada trazia algo introduzido em sua vagina. Desta forma, realizaram a abordagem e questionaram a ré sobre o referido volume, a qual retirou um invólucro da sua vagina e o apresentou, alegando que foi obrigada, sob ameaça, a introduzir tal objeto em seu corpo, por uma moça desconhecida, antes de entrar na penitenciária, e que lhe entregaria quando já estivessem dentro do estabelecimento prisional. Ressaltou que a acusada não identificou e não apontou quem seria a referida pessoa e que, com o apoio do agente penitenciário Delcio, observaram que no invólucro apresentado existia erva esverdeada semelhante a "maconha", a qual estava envolvida em uma substância de cor preta, semelhante a grafite, possivelmente com o objetivo de impedir a sua constatação pelo "scanner corporal". Por fim, esclareceu que acusada visitaria o seu companheiro Maxwell Sebilhano da Silva - matrícula n.º 775.605-9, que cumpre pena no estabelecimento prisional. Em juízo, ratificou integralmente a versão dada na fase inquisitiva.

Em solo policial (fls. 6), Delcio Anésio dos Santos, Agente Penitenciário, confirmou integralmente a versão dada pela agente Ana Pula. Em juízo, ratificou os fatos conforme narrados em solo policial e acrescentou que a ré disse que seu marido sequer sabia que ela levaria drogas e que apenas introduziu o entorpecente em seu corpo porque foi ameaçada por uma desconhecida antes de entrar na penitenciária. Por fim, salientou que a acusada não identificou a pessoa que a ameaçou, tampouco disse para quem entregaria o entorpecente.

Ouvido apenas perante a Autoridade Policial (fls. 137), Maxwell Sebilhano da Silva informou que está preso na Penitenciária de Marília e que não teve nenhuma participação na conduta de sua companheira Valquíria. Contou que ficou surpreso com a informação de que ré fora flagrada com drogas ao tentar entrar na penitenciária e salientou que nunca pediu que ela lhe trouxesse drogas em dias de visitas. Não soube dizer os motivos pelos quais a acusada estava tentando entrar com drogas no presídio e nada soube sobre ameaças que ela teria sofrido para praticar a referida conduta. Por fim, ressaltou não ter nenhum envolvimento no ocorrido.

Na fase inquisitiva, a acusada (fls. 7) afirmou que estava na entrada da penitenciária, aguardando o momento de visitar seu companheiro, Maxwell Sebilhano da Silva, quando foi abordada por uma mulher desconhecida, a qual não se recorda das características, que disse que ela deveria ingressar no estabelecimento prisional com a droga em sua vagina e lhe entregar, posteriormente, no banheiro, quando ambas estivessem dentro do presídio. Contou que, inicialmente, se negou, mas a tal mulher a ameaçou dizendo que, se ela não fizesse o que estava sendo ordenado, seu companheiro seria prejudicado "dentro do sistema" e que também iriam atrás de sua filha na escola, o que lhe causou espanto por ela saber até o nome da manor. Por fim, afirmou já ter passagens pela polícia e pelo sistema penitenciário. Em seu interrogatório judicial, confirmou a versão oferecida na fase inquisitiva e acrescentou que foi a mulher que a ameaçou que lhe deu a droga e a ensinou, no banheiro, a introduzir os entorpecentes em seu corpo para entrar na penitenciária. Narrou que tal mulher lhe disse para ser a primeira da fila destinada ao ingresso na penitenciária, porque, ao entrar, a ré ficaria no pátio com seu marido (que de nada sabia) e entregaria a droga à mulher no banheiro. Disse que não apontou quem seria a pessoa que proferiu as ameaças por estar com muito medo. Informou que já teve condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecentes. Afirmou que não contou das ameaças para os agentes penitenciários que se encontravam no "scanner", pois a mulher que lhe prometeu mal injusto e grave estava logo atrás na fila. Disse que seu marido está preso por tráfico ilícito de entorpecentes.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, oportuno advertir que os agentes penitenciários são agentes públicos que

gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoas inocentes, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas. Neste sentido: "Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais civis tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998) "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)" (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des. Otávio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.21).

Ainda, por analogia: "Anotar-se que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. O juiz não pode olvidar que, hodiernamente, os civis se recusam a depor por medo de represália (moram no mesmo reduto do tráfico, na mesma rua do suposto traficante preso etc.), de modo que o testemunho policial sempre se sobressai, merecendo o valor correspondente à realidade aferida. Não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente." (TJSP, Apelação Criminal nº 1501636-73.2019.8.26.0126, Des. Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.2021).

Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Nesse particular, registre-se que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, bem como as reiteradas informações anônimas sobre a traficância que foram confirmadas pelos agentes públicos, como ocorreu no presente caso. Ademais, a condição de as testemunhas

serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (STJ, Habeas Corpus nº 633.615 SP, Min. Félix Fischer, Decisão Monocrática, j. 27.1.2021).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos agentes penitenciários foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, confirmando-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar a ré.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que a acusada praticou conduta descrita nos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo, nas dependências de estabelecimento prisional, para entrega a consumo de terceiros, drogas sem autorização legal e regulamentar. Vejamos. Do exame dos autos, extrai-se que os agentes penitenciários flagraram a acusada trazendo consigo a droga ilícita, como consta no laudo de constatação (fls. 18/20) – ratificado por laudo de exame químico-toxicológico (fls. 127/130). Dado o objetivo da ré de ocultar a droga em sua genitália, somente com o auxílio de equipamento de segurança e monitoramento da penitenciária foi possível identificar tal conduta típica. Faz-se, portanto, insustentável qualquer alegação de insuficiência probatória, havendo sim provas seguras que atestam a conduta criminosa já narrada. Ainda, o fato de o companheiro da acusada, Maxwell, ter dito que não solicitou drogas a ela não é, por si só, suficiente para afastar a responsabilidade criminal de Valquíria.

A versão da acusada, de que foi ameaçada para adentrar à Penitenciária em posse da droga, encontra-se isolada das provas constantes nos autos, não sendo possível, assim, suscitar o instituto da coação moral irresistível. Afinal, poderia, a ré, procurar as autoridades competentes e contar, na primeira oportunidade, da ameaça que sofreu, o que não ocorreu no caso concreto. Preferiu ela arriscar-se a entrar com a droga no presídio e foi descoberta apenas porque, ali, há scanner.

Sobre o elemento subjetivo do tipo do artigo 33 da LD, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro “Lei de drogas comentada artigo por artigo” (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): “O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando à consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'”.

Neste contexto, observo que as circunstâncias da prisão da ré (presa em flagrante), as condições em que se desenvolveram a ação (levar entorpecentes ocultos em seu corpo à penitenciária), bem como seus antecedentes (já foi condenada anteriormente por tráfico ilícito de entorpecentes) revelam que se trata, a acusada, de traficante.

Por fim, no que se refere às alegações feitas pela defesa da ré no sentido da atipicidade da conduta (pelo fato de os entorpecentes não terem sido efetivamente entregues) e concernente ao fato de que o meio utilizado pela acusada seria absolutamente ineficaz, tratando-se, portanto, de crime impossível, cito pacificada jurisprudência em sentido diverso:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO COM O RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE DA CONASSAÇÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO RÉU DIEGO I – Impossível a decretação da absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas se os elementos probatórios reunidos durante todo o iter processual demonstram satisfatoriamente que os réus somaram esforços visando introdução de uma porção de maconha em unidade prisional.

O firme relato apresentado pelos policiais, devidamente secundado pelas confissões extrajudiciais e evidências que decorrem do flagrante, são todos elementos capazes de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, o fato criminoso narrado na denúncia. II – O crime impossível, previsto no art. 17 do CP, demanda a constatação acerca do irremediável prejuízo à consumação do delito em razão da ineficácia absoluta do meio empregado ou da absoluta impropriedade do objeto. Na hipótese vertente, o meio empregado pelos réus não seria suficiente para impossibilitar consumação do crime de tráfico de drogas, pois a submissão de visitantes a aparelhas eletrônicos ou à revista íntima não são capazes de inibir, com absoluta certeza, o ingresso de drogas em unidades prisionais. Ademais, a consumação do delito ocorreu no momento em que ré trouxe consigo a substância entorpecente, sendo irrelevante a ausência de tradição da substância entorpecente ao réu recolhido no estabelecimento penitenciário. Logo, não há falar em absolvição pela alegada impossibilidade de consumação do crime. (...) IV – Recurso improvido com o reconhecimento ex officio da atenuante da confissão espontânea em favor do réu Diego. (...) (TJ-MS - Apelação Criminal APR 00005405620198120007 MS 0000540-56.2019.8.12.0007)

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois provado que a acusada é reincidente específica, indicando, assim, que se dedica ao crime. Portanto, caracterizados o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provadas a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, vislumbro que a acusada é portadora de Maus antecedentes (fls. 37/39). Assim, fixo a pena 1/6 (um sexto) acima de seu patamar mínimo: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, que é inclusive específica (fls. 37/39), motivo pelo qual majoro a pena em, também, 1/6 (um sexto), restando a reprimenda de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do artigo, 40, inciso III da Lei de Drogas, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), que resta fixada em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é imposta em 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

No mais, fixo o regime inicial fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade pelo fato de se tratar de ré reincidente.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias da condenada, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do estabelecimento em que se encontra a presa, de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar VALQUIRIA DA SILVA GILARDI, qualificada nos autos, à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por ser incurso no artigo 33 c/c o artigo, 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, obedecidas as disposições da Lei n.8072/90 (crime equiparado a hediondo).

Nego a ré o apelo em liberdade. A gravidade em concreto das condutas por ela praticadas, já mencionada na decisão que decretou a prisão preventiva e nesta decisão confirmada demonstra a necessidade de continuidade da custódia. A ordem

pública deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face dos crimes e de sua repercussão. Ademais, sabedora da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal. Repisa-se que a acusada é reincidente específica.

Assim, recomende-se a ré na prisão em que se encontra recolhida.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas e cumprimento desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA